단시간근로자의 초과근로 가산임금 지급 관련 지침

2014. 9.

고용노동부
Ministry of Employment and Labor

【순　서】

1. 지침의 배경 ····· 1

2. 단시간근로자의 정의 ····· 2

(1) 비교대상근로자가 반드시 있어야 하는지 여부 ····· 2

(2) 통상근로자의 개념 정의 ····· 8

(3) 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자 ····· 8

3. 단시간근로자의 소정근로시간 ····· 12

(1) 1일의 소정근로시간을 정하지 않은 경우 초과근로 판단 12

(2) 소정근로시간의 변경이 가능한지 여부 ····· 13

(3) 소정근로시간을 집단적으로 정하는 경우 ····· 15

1 지침의 배경

□ 「근로기준법」 제56조는 **법정근로시간(1주 40시간)을 초과**하여 **연장근로**를 한 경우에만 **가산임금**을 **지급**하도록 규정하고 있음

○ 따라서 **소정근로시간**을 **초과**하여 **근로**를 제공하더라도 **법정근로시간을 초과하지 않은 경우**에는 **가산임금을 지급하지 않아도** 됨

□ 그러나 근로기준법 단시간근로자의 소정근로시간을 법정 근로시간 범위에서 정했음에도 **상시적으로 초과근로를 강요받는 경우가 많아** 이를 제한할 필요성이 대두됨

○ 이에 따라 **단시간근로자의 소정근로시간**을 **초과**한 **근로**에 대하여 **가산임금(50%)을 지급**하도록 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」이 개정됨

【관련 규정】

기간제법

■ **제6조(단시간근로자의 초과근로 제한)** ① 사용자는 단시간근로자에 대하여 **「근로기준법」 제2조의 소정근로시간을 초과**하여 근로하게 하는 경우에는 당해 근로자의 동의를 얻어야 한다. 이 경우 **1주간에 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다.**

② 단시간근로자는 사용자가 제1항의 규정에 따른 동의를 얻지 아니하고 초과근로를 하게 하는 경우에는 이를 거부할 수 있다.

③ 사용자는 **제1항에 따른 초과근로에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급**하여야 한다. ('14. 3.18 신설)

□ **'14.9.19.부터** 동 규정이 **시행**됨에 따라 **단시간근로자 정의, 소정근로시간의 변경** 등 몇 가지 쟁점에 대해 통일적 해석을 위하여 지침을 마련함

2 단시간근로자의 정의

❖“**단시간 근로자**”란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧을 근로자를 말한다. (**근로기준법 제2조제1항제8호**)

(1) 비교대상근로자인 통상근로자 반드시 있어야 하는지 여부

○ 현행 「근로기준법」은 단시간 근로자를 **1주 동안의 소정근로시간**이 **통상근로자보다 짧은 근로자로 정의**함

- 즉, 근로기준법상 **단시간근로자 개념**은 해당 사업장에 비교대상 근로자인 **통상근로자의 존재를 전제**로 함

○ 따라서 특정 사업장의 근로자들의 소정근로시간이 모두 동일한 경우 등 통상근로자가 없는 경우에는 1주 동안의 소정근로시간이 법정근로시간 보다 짧더라도 단시간근로자로 볼 수 없음

사 례

◈ **소정근로시간과 근무조건이 동일하여 통상근로자가 없는 경우**

구분	근무일수	소정근로시간
A	주 5일	주 25시간
B	주 5일	주 25시간
C	주 2일(주말)	주 25시간
D	주 2일(주말)	주 25시간
E	주 2일(주말)	주 25시간

☞ 사업주를 제외하고 5명의 아르바이트 근로자가 모두 판매 업무를 수행하고 **소정근로시간이 동일한 경우** 비교대상 근로자가 없어 A, B, C ,D, E 근로자 **모두 단시간근로자로 볼 수 없음**

(2) 통상근로자의 개념 정의

□ 통상근로자와 단시간근로자의 구별 기준

○ 근로기준법 제2조 제1항 제8호에서 단시간근로자를 "통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자"라고 전제하고,

- 같은 법 제18조에서 단시간근로자의 근로조건을 통상 근로자의 근로시간에 비례하여 정하도록 규정한 점에 비추어 볼 때,

- 통상근로자와 단시간근로자의 **중요한 구별 기준**은 "**소정근로시간**"임

□ 사업장에 1주 40시간으로 소정근로시간을 정한 근로자가 있는 경우

○ 근로기준법은 1일 8시간, 1주 40시간(법정근로시간) 근로를 하는 전일제 근로자를 기본으로 규정하고 있음

* 근로기준법 시행령 별표 2(단시간근로자의 근로조건 결정기준 등에 관한 사항)은 **단시간근로자의 연차유급휴가**를 통상근로자의 연차휴가일수에 **통상근로자의 소정근로시간에 비례**하여 산정하도록 규정하고 있으며 **통상근로자의 연차휴가 일수에 대하여 별도의 규정이 없으므로** 법 제60에 따른 연차유급휴가 일수를 전제로 한 것으로 볼 수 있으며 이는 **1주 40시간을 전제로 규정**한 것임

- 위와 같은 **1주 40시간의 근로를 제공하는 근로자**가 해당 **사업장에 있는 경우 그를 통상근로자**로 보고 그와 동종 업무에 종사하는 1주 동안의 소정근로시간이 그 보다 짧은 근로자를 단시간근로자로 판단

□ 사업장에 1주 40시간으로 소정근로시간을 정한 근로자가 없는 경우

○ 해당 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 근로자 중 1주 동안의 **소정근로시간이 가장 긴 근로자**를 통상근로자로 보고

- 그 근로자보다 1주 동안의 소정근로시간이 짧은 근로자를 단시간근로자로 판단

사례

◈ **(사례 1) 통상근로자와 근로조건이 동일하며 정규직이지만 소정근로시간이 1주 40시간 미만인 근로자를 단시간근로자로 볼 수 있는지 여부**

○ 특정 기업에는 **주당 소정근로시간이 40시간인 Full Time 사원**(“FT사원”)과 **주 25시간에서 40시간 이내**(평균 1주 38시간)로 **주마다 유동적으로 근무**하는 **Part Time 사원**(″PT사원“)이 있음

- 동 기업의 인사원칙에 따라 주 소정근로시간의 장단을 제외하고는 “FT사원”과 ″PT사원“ 사원간에는 임금, 휴가, 승진, 휴직 그밖에 복리후생 등 **모든 근로조건이 동일**하고, 모두 **기한의 정함이 없는 근로계약을 체결한 정규직 신분**으로 정년의 정함이 없다는 점도 동일함

☞ 사업장에 소정근로시간이 1주 40시간인 **Full Time인** 근로자가 있는 경우에는 동 근로자를 통상근로자로 보고 그와 같은 업무에 종사하는 소정근로시간이 1주 40시간 미만인 근로자를 단시간근로자로 보아야 함

◈ **(사례 2) 편의점에서 사업주를 제외하고 5명의 아르바이트 근로자가 모두 판매업무를 수행, 소정근로시간이 1주 40시간인 아르바이트 근로자를 통상근로자로 볼 수 있는지 여부**

구분	근무일수	근무시간	소정근로시간	비고
A	주 5일	23~08	**주 40시간**	기간제
B	주 5일	18~23	주 25시간	〃
C	주 2일(주말)	23~08	주 16시간	〃
D	주 2일(주말)	12~18	주 12시간	〃
E	주 2일(주말)	18~23	주 10시간	〃

☞ A가 **1주 소정근로시간이 주 40시간**이므로 **다른 근로조건의 비교 없이** 소정근로시간이 1주 40시간인 A를 통상근로자로 보고 B, C, D, E는 단시간근로자로 보아야 함

◈ **(사례 3) 편의점에서 사업주를 제외하고 5명의 아르바이트 근로자가 모두 판매업무를 수행, 아르바이트 근로자를 통상근로자로 볼 수 있는지 여부**

구분	근무일수	근무시간	소정근로시간	비고
A	주 5일	23~08	**주 35시간**	기간제
B	주 5일	18~23	주 25시간	〃
C	주 2일(주말)	23~08	주 16시간	〃
D	주 2일(주말)	12~18	주 12시간	〃
E	주 2일(주말)	18~23	주 10시간	〃

☞ A의 소정근로시간이 35시간으로 같은 사업장의 근로자 중 소정근로시간이 가장 긴 근로자이므로 A가 통상근로자에 해당함

참고 1 통상근로자 판단과 관련한 견해

<1> 기존의 행정해석

○ "통상근로자"란 **소정근로시간 뿐만 아니라** 사업장의 **고용형태, 임금체계** 등을 **종합적으로 고려하여 통상적으로 근로할 것이 예정**된 **정규직 근로자**를 말함

- 또한, **취업규칙 등**에 의하여 채용 및 계약기간, 임금 호봉, 승진 등 **중요한 근로조건 대부분이 직접 규율**되고 있는 근로자로서 **그 업무에 종사하는 가장 일반적인 형태의 근로자**를 말함

<2> 견해의 대립

□ **사업장 내의 1주 동안 "소정근로시간이 40시간인 근로자"라는 입장**

○ 일반적으로 단시간근로자란 1주 40시간보다 짧게 근로하는 근로자로 통용되고 있으며,

- 법정 근로시간 내 가산수당 지급의 입법취지가 법정근로시간보다 짧은 근로시간을 정한 근로자를 보호하려는 것임

○ **근로기준법**은 1일 8시간, **1주 40시간 근로를 하는 전일제 근로**를 **기준으로 규정**하였고

- 법정근로시간을 기준으로 **근로시간의 비율에 따라 단시간근로자의 근로조건을 결정**하도록 규정하고 있으므로 통상근로자란 법정근로시간을 소정근로시간으로 정한 근로자로 보아야 함

□ **1주 동안의 "소정근로시간이 가장 긴 근로자"라는 입장**

○ 통상근로자와 단시간근로자의 **중요한 구별 기준**은 "**소정근로시간**"이지만 통상근로자를 소정근로시간이 법정근로시간인 근로자로 한정할 근거가 없으며

- 소정근로시간이 가장 긴 근로자를 통상근로자로 보고 시간비례 보호 원칙에 따라 단시간근로자의 근로조건을 결정할 수 있음

□ **1주 동안의 “소정근로시간이 40시간인 근로자”로 하되, 해당 사업장의 기준 소정근로시간을 40시간미만으로 볼 여지가 있는 경우에는 40시간 미만인 근로자를 통상근로자로 본다는 입장**

○ 1주 동안의 “소정근로시간이 40시간인 근로자”로 하되,

- 취업규칙이나 단체협약에서 기준근로시간을 1주 40시간미만으로 정한 경우이거나

- 대다수의 근로자들의 근로계약서에 소정근로시간이 1주 40시간 미만으로 되어 있고 근로조건도 시간에 비례하는 아니라 「근로기준법」을 그대로 적용시키고 있는 등 그 사업장의 기본적인 소정근로시간이 1주 40시간 미만이라고 볼 여지가 있는 경우에는

- 소정근로시간을 **1주 40시간미만으로 정한 근로자**들을 **통상근로자**로 볼 수 있음

□ **그 사업장 내에서 가장 일반적인 형태의 근로자를 말하므로 다수의 고용형태의 차지하는 근로자라는 입장**

○ ‘통상적’이란 특별하지 아니한 것으로 사전적 의미로 해석하여 그 사업장 내에서 가장 다수를 차지는 소정근로시간을 정한 근로자를 통상근로자로 판단

○ 이 경우, **소정근로시간이 법정근로시간보다 짧은 근로자가 다수**를 **차지**하는 사업장의 경우에는 그 근로자들이 통상근로자가 됨

- 해당 사업장 내에서 **가장 다수를 차지하는 소정근로시간**으로 근로계약을 체결한 근로자가 통상근로자가 되며

- 법정근로시간보다 짧은 근로자 사이에도 통상근로자와 단시간근로자로 나누어질 수 있으며 가장 다수를 차지하는 근로자보다 소정근로시간이 긴 근로자는 통상근로자도 단시간근로자도 아니게 됨

○ 특히, 소정근로시간이 법정근로시간 보다 짧은 근로자의 경우에도 통상적으로 근로할 것이 예정되어 있는 정규직근로자로서 중요한 근로조건 대부분이취업규칙 등에 의하여 직접 규율되고 있으며

- 임금, 휴가, 승진, 그 밖에 근로조건이 1주 40시간 근로자와 동일한 경우에는 1주의 소정근로시간이 짧은 경우에도 동 근로자를 해당 사업장의 통상근로자로 판단하여야 함

□ **사업장 단위로 제한하지 않고 1주 동안의 소정근로시간이 40시간인 근로자를 통상근로자로 하여야 한다는 입장**

○ 현행 근로기준법에 따르면 통상 근로자는 '그 사업장'단위로 판단해야 하는 것이 원칙임

- 그러나 사업장 단위로만 통상근로자를 판단하게 될 경우에는 동일하게 근로시간이 법정근로시간 보다 짧은 근로자라고 하더라도 초과근로에 대한 가산임금 지급기준이 사업장별로 달라지게 되고, 최저근로조건도 달리 적용되는 현상이 발생하며

- 또한, 같은 사업장에서 모든 근로자가 법정 근로시간보다 짧게 소정근로시간을 정하였음에도 불구하고 특정 근로자만 통상근로자가 되어 근로자간 형평에 반하는 결과 초래

○ 따라서 통상근로자는 1주 동안의 소정근로시간이 40시간인 근로자로 보되,

- 법정 근로시간 내의 초과근로에 대한 가산임금 지급 규정의 입법취지 등을 감안하여 사업장에 관계없이 1주 40시간의 법정근로시간 미만인 근로자는 단시간근로자로 해석하여야 함

참고 2 차별시정 판단 시 통상근로자 판단 사례

□ 경북대학교 시간강사 차별시정 사례

○ 경북대학교의 시간강사는 학기단위로 위촉되어 한 학기에 주당 **9시간 이내**의 강의업무만이 부여되는 **기간제근로자**이며

- 경북대학교의 전임강사는 2년 단위로 임용되어 **1주 동안 40시간의 소정근로시간** 동안 강의 및 연구업무가 부여되는 기간제근로자

⇒ 해당 사건에서 **1주 40시간 근로자를 통상근로자로 판단**하고 시간강사를 단시간근로자로 보아 차별여부를 판단함
(행정법원 2009. 2. 6. 선고 2008구합22747판결)

□ 대구대학교 시간강사 차별시정 사례

○ 대구대학교는 강의를 주로 담당하기 위하여 주당 책임시간 15시간으로 하고 최대 임용기간을 3년으로 하여 1년 단위로 계약하여 임용되는 **강의전담교수**를 두고 있으며

- 강의전담교수는 시간강사와 해당 사업 또는 사업장에서 동종 유사한 업무에 종사하는 근로자에 해당한다 할 것이므로

⇒ 위 사건에서 소정근로시간이 **1주 15시간인 강의전담교수**를 통상근로자로 판단하고 시간강사를 단시간근로자로 보아 차별시정 여부를 판단함 (행정법원 2009. 6. 3. 선고 2008구합24743 판결)

참고3 외국의 단시간근로자에 개념 정의

1 ILO: 1994년 단시간근로협약(제175호)

○ **단시간 근로자**란 '비교대상이 되는 통상근로자에 비하여 통상적인 근로시간이 짧은 자'를 말한다고 규정

○ **비교대상이 되는 정규근로자**는 "관련된 단시간근로자와 동일한 형태의 고용관계를 맺고 있고, 동일한 사업장에 고용되어 동일·유사한 형태의 작업이나 직업에 종사하는 자"를 말하여

- 동일한 사업장에 비교대상이 되는 정규근로자가 없는 경우에는 "동일한 기업에서의 그러한 자, 동일한 기업에도 존재하지 않는 경우에는 동일한 산업분야에서 그러한 자"로 규정

2 독일: '단시간근로자와 기간제 근로계약에 관한 법률 제2조

❖ **"단시간근로자"란 통상적인 주당 근로시간**이 그 업무 내용에 있어 유사하여 비교 가능한 **전일제 근로자**에 비하여 **더 짧은 근로자**를 말한다고 규정

○ 전일제 근로란 사업장의 통상적인 주당(법정근로시간 범위에서 정해지는) 근로시간 전체를 100% 감당하는 근로를 말함

- 따라서 전일제 근로자와 전일제 근로시간이란, 해당 사업장에서 법정근로시간 범위에서 근로시간을 가장 길게 약정한(=소정근로시간이 가장 긴) 근로가가 기준이 됨

* 상시근로자수가 30명인 사업장에서 소정근로시간이 1주 35시간인 근로자가 1명, 30시간인 근로자가 29명이 있다면 소정근로시간이 35시간인 근로자가 전일제근로자가 되고, 나머지 29명의 근로자가 단시간근로자가 됨

○ 만일, 통상적인 주간근로시간에 대한 합의가 없다면 1년의 기간을 한도로 한 고용기간 동안의 통상적인 **평균 근로시간이 비교 가능한 통상근로자보다 적은 근로자가 단시간 근로자에 해당**함

- 해당 사업장 내에 비교가능한 통상근로자가 없는 경우에는 적용 가능한 단체협약의 적용대상이 되는 자, 나아가 통상적으로 동일한 산업분야에 종사하는 자를 비교대상으로 하고 있음

3 일본: 단시간근로자의 고용관리의 개선 등에 관한 법률 제2조

❖ **"단시간근로자"란** 1주간의 소정근로시간이 동일한 사업장에 고용된 통**상의 근로자의 1주일의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자**를 말한다고 규정

○ **통상근로자**란 당해 업무에 종사하는 자 중에서 소위 정규형의 근로자가 있는 경우에는 **당해 정규형의 근로자**를 말하고

- 여기서 **정규형의 근로자**란 사회통념에 따라 당해 근로자의 고용형태, 임금체계 등(가령 근로계약기간의 정함이 없고 장기고용을 전제로 한 대우를 받는 자인가, 임금의 주된 부분의 지급형태, 상여, 퇴직금, 정기적 승급 또는 승격 유무)을 종합적으로 감안하여 판단

○ 정규형의 근로자가 없는 경우에는 당해 업무에 기본적으로 종사하는 **풀타임근로자가 있으면 이 근로자**를 **통상근로자**로 해석함

(3) 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자

□ 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자가 없는 경우

○ 「근로기준법」은 해당 근로자의 1주 동안의 소정근로시간이 통상근로자보다 짧은 경우에도 해당 통상근로자와 **같은 종류의 업무에 종사하는 경우에 한하여** 단시간근로자로 봄

- 따라서, 현행 「근로기준법」의 해석상 "**같은 종류의 업무**"에 종사하는 **통상근로자가 없는 경우에는** 1주 동안의 소정근로시간이 통상근로자보다 짧은 경우에도 **단시간근로자가 될 수 없음**

□ 같은 종류의 업무의 범위

○ "동종 업무" 여부는 업무의 수행방법, 작업의 조건, 업무의 난이도 등을 종합적으로 고려하여 판단하되,

- 같은 직군 또는 직종에 종사하는 경우에는 **같은 종류의 업무에 종사하는 근로자로 판단**함이 합리적임

  * 「기간제법」 제8조제2항의 차별적 처우 금지 규정의 "동종·유사업무에 종사하는 통상근로자의 "동종·유사 업무"보다는 넓게 판단함

○ 이 경우 "동종 업무" 여부는 **실제 업무 내용을 따져 판단**하되,

- 해당 사업장의 취업규칙이나 단체협약의 규정, 사회보험 관련한 취급 실태 등도 함께 살펴보아야 함

통상근로자에 대한 해석

○ 「근로기준법」상 단시간근로자 정의의 "동종업무" 여부는 당해 업무의 수행방법, 작업의 조건, 업무의 난이도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며

- 특히 업무의 이질성으로 인해 근로조건이 현저하게 구별되어 규정되는지 여부가 중요함(2002-3-26- 근기68207-1248) 68207-1248, '02. 3. 26.)

2 단시간근로자의 소정근로시간

(1) 1일의 소정근로시간을 정하지 않는 경우 초과근로 판단

□ 기간제법 제17조에 따른 근로조건 명시 의무 위반 여부

○ 「기간제법」 제17조는 단시간근로자와 근로계약 체결 시 **근로일 및 근로일별 근로시간을 서면으로 명시**하도록 규정

* **기간제법 제17조(근로조건의 서면명시)** 사용자는 기간제근로자 또는 단시간근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 다음 각 호의 모든 사항을 서면으로 명시하여야 한다. 다만, 제6호는 단시간근로자에 한한다.
6. 근로일 및 근로일별 근로시간

- 따라서, 사용자가 단시간근로자와 근로계약 체결 시 **근로일 및 근로일별 근로시간**을 **서면으로 명시하지 않은 경우**에는 **500만원 이하의 과태료 부과**

□ 1일의 소정근로시간을 서면으로 정하지 않은 경우의 소정근로시간

* **근로기준법 제2조제1항제7호** "소정근로시간"이란 제50조, 제69조 본문 또는 「산업안전보건법」 제46조에 따른 근로시간의 범위에서 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간을 말한다.

○ 기간제법 제17조에 따라 **서면 근로계약서**에 **'근로일 및 근로일별 근로시간'이 기재**되어 있는 경우

- 해당 근로계약서는 이른바 처분문서로서 특별한 사정이 없는 한 그에 따라 **당사자들이 합의한 시간**을 **소정근로시간**으로 **판단**

○ 그러나 1주 동안의 소정근로시간만 정하고 1주 동안의 **근로일 및 근로일별 소정근로시간을 서면으로 정하지 않은 경우**

- 서면에 명시하지 않았지만 **통상적으로 근로를 제공하기 위해서는** 구두 또는 묵시적으로 **1일의 근로시간을 정할 수밖에** 없으므로

- 사용자와 근로자의 **근로계약 체결 시의 의사해석을 통해** 소정근로시간을 판단하여야 함

(2) 소정근로시간의 변경이 가능한지 여부

□ 단시간근로자의 소정근로시간을 변경할 수 있는지 여부

○ 「근로기준법」 제17조는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 소정근로시간 등이 명시된 서면을 교부하도록 하고 이를 변경하는 경우에도 동일한 의무를 부과하고 있으므로

- 소정근로시간 변경이 가능함을 전제로 한 것으로 볼 수 있으며 소정근로시간이 반드시 고정적일 필요는 없음

- 따라서, 근로계약을 체결 한 후에도 사용자와 근로자의 **명시적이고 확정적인 합의**에 따라 **근로시간 등 근로조건을 변경**할 수 있다고 해석됨

  * 근로계약기간 도중 특정근로자의 1주 또는 1일의 소정근로시간을 회사와 당해 근로지간 서면 또는 구두로 합의를 통해 변경가능(2013.2.20. 근로개선정책과-1290)

□ 가산임금 지급을 회피할 목적으로 소정근로시간을 변경하는 경우

○ 법정근로시간 내 초과근로에 대한 **가산임금 지급을 회피할 목적으로 소정근로시간을 변경하는 경우에는** 소정근로시간의 변경 여부에 관계없이 **애초에 정한 소정근로시간을 초과한 근로에 대하여 가산임금을 지급하도록 해석**

- 예를 들어▲취업규칙 등으로 주간 또는 월간 근무표를 작성한 후 **일부 근로자와 사이에 특정일에만 소정근로시간을 변경**하거나 ▲총 소정근로시간의 변경은 없으면서 특정일의 소정근로시간을 조정하거나▲특별한 사정없이 **소정근로시간의 변경 횟수가 잦은 경우 등**에는 **가산임금 지급**을 **회피할 목적**이 **추정**될 것으로 보임

- 위 경우에 해당함에도 "가산임금 지급을 회피할 목적이 아님"은 **사용자가 입증**하여야 함

□ 1주 동안의 소정근로시간 범위에서 사용자가 임의적으로 근로시간을 운용할 수 있는지 여부

○ 법정 근로시간 내의 초과근로에 가산임금 지급 부담을 피하기 위하여 소정근로시간을 최대한 넉넉하게 정해놓고 실제 근로시간은 **소정근로시간 범위에서 사용자의 임의대로 운용하는 경우**

사례

◈ 통상적으로 1주 5일, 1일 4시간의 단시간근로자를 사용하여 왔는데, 소정근로시간을 초과한 근로 시 가산임금 지급이 부담이 되어 1일 6시간으로 근로시간을 정하고 실제 근로는 4시간을 기본으로 하되, 때때로 6시간 근무하도록 하여 4시간을 초과한 2시간 근로에 대해서는 가산임금을 지급하지 아니함

- 근로계약 시 명시적으로 정한 **소정근로시간 범위** 내의 **근로**에 대해서는 초과근로 시 가산임금 지급의 회피 목적에 관계없이 **원칙적으로 가산임금을 지급할 의무가 없음**

○ 그러나 근로계약 시 1주 동안의 소정근로시간을 명시적으로 정하였음에도 사용자가 특별한 사정없이 근로자의 **소정근로시간 만큼의 근로제공에 대한 수령을 거부**하는 경우

- 경영상의 장애 등 **사용자의 "휴업"**으로 인한 때에는 근로자에게 「근로기준법」 **제46조의 휴업수당 청구권**이 발생하고 **평균임금의 70%**를 지급받을 수 있지만

- 사용자의 귀책사유 등으로 인한 휴업이 아니라 **일방적인 수령거부인 경우**에는 **민법 제538조의 채권자의 귀책사유로 인한 이행불능에 해당**하므로 근로자에게 사용자가 수령하지 않은 소정근로시간 부분의 **임금 전액에 대한 청구권**이 발생함

(3) 소정근로시간을 집단적으로 일정기간 단위로 정하는 경우

□ 사업장의 근로자집단별로 일정 단위기간 동안의 총 소정근로시간 및 특정주 또는 특정일별 근로시간을 변경할 수 있는지 여부

○ 단시간근로자의 근로일 및 근로일별 소정근로시간을 근로자대표와의 합의(또는 취업규칙)로 일정기간 단위로 정하는 경우에도

- **총 소정근로시간** 및 **특정주 또는 특정일별 근로시간을 변경**할 수 있다고 판단됨

○ 다만, 단위기간이 시작 된 후 근무평성표를 조정하여 소정근로시간을 변경하는 것은 **근로자가** 사전에 **근로시간을 예측할 수 없게** 되고

- **가산임금 지급을 면탈하려는 것으로 해석**될 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한 **"단위기간 시작 전까지만 변경이 가능"**하다고 해석함이 합리적임

□ 근로자집단별로 소정근로시간 및 특정주 또는 특정일별 근로시간을 정한 경우 소정근로시간의 변경 시기 및 방법

○ 탄력적 근로시간제는 근로자대표와의 합의를 통해 정하므로 개별근로자와의 합의가 아닌 **"근로자대표와의 합의" 등을 통해** 단위기간 동안의 **소정근로시간을 변경함**이 타당함

- 이 경우 "근로자대표"는 근무편성표 등의 적용대상자를 기준으로 과반수 여부를 판단하여야 함